

Réforme du régime de dévolution des droits de propriété intellectuelle sur les actifs obtenus par des auteurs de logiciels ou inventeurs non-salariés ni agents publics accueillis par une personne morale réalisant de la recherche

Vers un rapprochement avec le régime de droit commun des inventeurs et auteurs salariés



Date : 15 mai 2022 (fiche initiale relative à l'Ordonnance)

17 mai 2024. Mise à jour de la fiche pour tenir compte des apports des différents décrets pris en lien avec l'ordonnance.

Co-auteurs :

Aurélie POINSOT, Aquitaine Science Transfert

Elodie DOS SANTOS, INSAVALOR

Jeremy PAPPALARDO, MCE CARREL

Pascale BOUVIER-MARION, Université Clermont Auvergne

Marin PELLE, MCE CARREL

Diana CHEIKH, Anotech Energy for Total Energies Global Procurement

Veronika NICOLOVA, Université Toulouse Jean Jaurès

La présente note est issue des travaux du groupe de travail C.U.R.I.E. Elle ne prétend pas à l'exhaustivité et ne peut engager la responsabilité de leurs auteurs. Elle est fournie uniquement à titre d'information. Elle ne saurait en tout état de cause se substituer à la lecture des dispositions législatives, réglementaires et de la jurisprudence applicable en la matière. Elle peut être amenée à évoluer.

Table des matières

1	INTRODUCTION	4
1.1	CONTEXTE DE L'ORDONNANCE	5
1.2	SYNTHESE DU DECRET « INVENTEURS »	5
1.3	SYNTHESE DU DECRET « AUTEURS »	6
1.4	HISTORIQUE DES TEXTES.....	7
2	LES PERSONNES ET LES STRUCTURES CONCERNEES	8
2.1	LES AUTEURS DE LOGICIELS ET LES INVENTEURS	8
2.2	LES STRUCTURES D'ACCUEIL	9
3	LES CRITERES D'APPLICATION.....	10
3.1	UN ACCUEIL FORMALISE PAR UNE CONVENTION	10
3.2	UNE SITUATION D'AUTORITE VIS-A-VIS D'UN RESPONSABLE DE LA STRUCTURE D'ACCUEIL	11
3.3	UNE CONTREPARTIE	11
3.4	CONTREPARTIE VS. PRIME D'INTERESSEMENT	14
3.5	DES EXCEPTIONS ?	15
4	LES ACTIFS VISES	15
4.1	LES LOGICIELS, LEUR DOCUMENTATION ET LES INVENTIONS.....	15
4.2	... CREES A L'OCCASION D'UNE MISSION OU ACTIVITE CONFIEE PAR LA STRUCTURE D'ACCUEIL	16
	<i>Apport des décrets du 11 août 2023.....</i>	<i>17</i>
5	LITIGES	18
6	CONCLUSION.....	19
7	RESSOURCES ET LIENS UTILES.....	20

1 Introduction

Par une ordonnance du 15 décembre 2021 (« **l'Ordonnance** »), le Gouvernement a modifié les règles de dévolution des droits de propriété intellectuelle relatifs aux inventions brevetables et aux logiciels originaux (ensemble désignés « **Actifs** ») réalisés par des personnes qui ne sont ni salariée, ni agent public (ensemble désignés « **Créateurs Indépendants** »). Cette Ordonnance propose ainsi une solution légale nouvelle à certaines difficultés posées par la situation des Créateurs Indépendants qui génèrent des Actifs dont le régime de propriété pouvait parfois être confus.

Par ailleurs, pour analyser l'Ordonnance, nous nous référons également au Rapport au Président de la République relatif à l'Ordonnance (« **Rapport au Président de la République** » - lien disponible en fin de note).

Le cas particulier des étudiants et des stagiaires donne lieu depuis de nombreuses années à des difficultés pratiques très abondantes et a été l'occasion d'une saga judiciaire célèbre dite « affaire Puech c. CNRS », laquelle avait entre autres permis au Conseil d'Etat de rappeler que *“la propriété des inventions faites par les étudiants non rémunérés (...) relève donc de la règle posée par l'article L.611-7 [du code de la propriété intellectuelle] attribuant cette propriété à l'inventeur ou à son ayant cause”*.

C'est pour apporter des éléments de réponse à cette situation délicate que l'Ordonnance a été prise **et plusieurs décrets sont venus en préciser l'application**.

N.B. : cette note a vocation à présenter les éléments propres à la réforme et non pas à rappeler les principes, exceptions et nuances du régime de droit commun des Actifs de salariés ou agents publics, bien que l'Ordonnance soit souvent construite par analogie avec ce régime.

1.1 Contexte de l'Ordonnance

Le droit de la propriété intellectuelle fixe un principe selon lequel l'auteur d'une œuvre ou l'inventeur d'une invention est propriétaire de sa création. Ce principe est immédiatement assorti d'exceptions, en particulier pour couvrir la situation majoritaire des auteurs de logiciels et inventeurs salariés ou assimilés. Dans un souci d'efficacité, la loi organise pour eux une dévolution automatique à l'employeur des droits couvrant leur création. Dans un souci de simplification louable, l'Ordonnance vient créer un régime pour les Créateurs Indépendants qui se rapproche de celui des créateurs salariés et agents publics.

L'Ordonnance ajoute ainsi deux mécanismes de dévolution des droits de propriété intellectuelle sur les Actifs par des Créateurs Indépendants lorsqu'ils sont accueillis par une personne morale réalisant de la recherche. En pratique, lorsque les conditions sont réunies, les droits de propriété intellectuelle relatifs aux Actifs réalisés par des Créateurs Indépendants sont automatiquement attribués à la structure d'accueil des Créateurs.

Bien entendu, compte tenu de leur objet même, ces deux mécanismes ne s'appliquent que dans le cas où les personnes concernées ne relèvent pas des régimes de droit commun des auteurs/inventeurs salariés. Bien que similaires à ce régime de droit commun, il faut noter que ces mécanismes ne sont applicables que sous certaines conditions.

Par ailleurs, le simple fait qu'une personne non salariée réalise une mission de recherche dans le cadre d'un contrat ne suffit pas à imposer l'application de ces nouveaux mécanismes puisqu'il faut qu'elle soit "accueillie" au sein de la personne morale réalisant de la recherche.

Il faut d'ores et déjà noter que, comme c'est l'habitude en la matière, les dispositions applicables aux auteurs de logiciels et aux inventeurs sont proches, mais elles ne sont pas identiques. Par exemple, le nouvel article L.113-9-1 relatifs aux auteurs de logiciels s'applique "*sauf stipulations contraires*" alors que le nouvel article L.611-7-1 concernant les inventeurs s'applique "*sauf stipulation plus favorable à [l'inventeur]*". De mêmes les modalités de rémunération des Créateurs Indépendants ne sont pas identiques lorsque l'Actif est un logiciel ou une invention. Il conviendra donc parfois d'envisager distinctement certaines modalités propres à l'un ou l'autre des mécanismes.

1.2 Synthèse du décret « inventeurs »¹

Les dispositions de ce décret pertinentes au titre de la présente note ont été codifiées aux articles R.611-21 et R.611-22 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Pour les inventions générées par un Créateur Indépendant, accueilli par une personne morale réalisant de la recherche, le décret prévoit les modalités de dévolution de la propriété ou de la jouissance de tout ou partie des droits de propriété industrielle attachés à l'invention au bénéfice de la structure d'accueil, ainsi que la contrepartie financière due au Créateur Indépendant.

Ainsi, les publics concernés par ce décret sont :

- les inventeurs
- sans contrat de travail ni statut d'agent public
- qui sont accueillis par une personne morale réalisant de la recherche.

¹ Décret n° 2023-770 du 11 août 2023 relatif aux modalités de dévolution des droits de propriété industrielle sur les actifs obtenus par des inventeurs non-salariés ni agents publics accueillis par une personne morale réalisant de la recherche : <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000047964851>

Le décret prévoit une application dans le temps qui tient compte de la date de la déclaration d'invention.

Contrairement au décret relatif aux logiciels (voir section suivante), ce décret s'applique aux personnes morales de droit public et privé.

Le décret tend à aligner le régime relatif aux inventions des Créateurs Indépendant avec le régime de droit commun des inventeurs salariés ou agents publics.

1.3 Synthèse du décret « auteurs »²

Ce décret traite des modalités d'intéressement des Créateurs Indépendants de logiciels accueillis par une personne morale de droit public réalisant de la recherche dont les personnels permanents de recherche sont des agents publics.

Il ne s'applique qu'aux personnes morales de droit public. Cela s'explique par le fait que l'objectif des décrets est de rapprocher le régime applicable aux Créateurs Indépendants de celui applicable aux salariés et agents publics. Or, seuls les agents publics bénéficient d'un droit légal à rémunération complémentaire.

Du point de vue de son application dans le temps, les dispositions du décret sont applicables à l'ensemble des logiciels créés postérieurement à l'entrée en vigueur de l'Ordonnance de 2021 pour laquelle le décret a été pris.

² Décret n° 2023-772 du 11 août 2023 relatif à l'intéressement des auteurs de logiciels non-salariés ni agents publics accueillis par une personne morale de droit public réalisant de la recherche dont les personnels permanents de recherche sont des agents publics : <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT0000047964885>

1.4 Historique des textes

	Logiciels	Inventions
Ordonnance 2021-1658	Création du nouveau régime des Créateurs Indépendants (L.113-9-1 du Code de la propriété intellectuelle)	Création du nouveau régime applicable aux Créateurs Indépendant (L.611-7-1 du Code de la propriété intellectuelle)
Décret 2023-770		Fixation des modalités de rémunération (R.611-21 et R.611-22 du Code de la propriété intellectuelle) Précision des modalités d'application dans le temps à l'article 4 (non codifiées)
Décret 2023-772	Fixation des modalités de rémunération (Non codifiées). Précision des modalités d'application dans le temps à l'article 4 (non codifiées)	
Décret 2023-1321	Abrogation du décret 772 et codification dans le code de la recherche (D.532-7 à -9) (pour info) Abrogation du Décret n°96-858 sur les « travaux valorisables » et codifié dans le code de la recherche (D.532-2 à -6)	

2 Les personnes et les structures concernées

2.1 Les auteurs de logiciels et les inventeurs

L.113-9-1 Auteurs de logiciels	L.611-7-1 Inventeurs
« personnes qui ne relèvent pas de l'article L. 113-9 »	« personnes physiques qui ne relèvent pas de l'article L. 611-7 »
Sont exclues toutes les personnes : • employées agissant dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur ; • agents de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif.	Sont exclues toutes les personnes : • salariées ; • agents de l'Etat, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public.

L'Ordonnance définit le champ d'application de son nouveau mécanisme par la désignation des personnes qui en sont exclues. En bref, **sont exclues** les personnes physiques qui sont titulaires d'un contrat de travail ou du statut d'agent public dans leurs relations avec leur employeur.

Sont concernées explicitement selon le Rapport au Président de la République :

- Stagiaires : oui
- Doctorants étrangers : oui
- CAS PARTICULIER des Professeurs et directeurs émérites :
La Commission relève que le Rapport au Président de la République désigne expressément les émérites, ce qui entre en contradiction avec l'article L. 952-11 du code de l'éducation, lequel dispose expressément qu'ils sont soumis aux dispositions des articles L.113-9 et L.611-7³. Selon la Commission, la loi matérialisée par le code de l'éducation prévaut sur le Rapport au Président qui n'est qu'un instrument d'aide à l'interprétation de l'Ordonnance. Les émérites sont donc soumis au régime de droit commun et non à l'Ordonnance.

Sont concernés selon toute vraisemblance, s'ils respectent les autres conditions de l'Ordonnance :

- Doctorant non-salarié (étranger ou non),
- Etudiant non-stagiaire (VIE, projet universitaire),
- Le bénévole intervenant au sein d'une structure d'accueil (dans ce cas le critère de la contrepartie devra particulièrement être analysé).

³ Art. L. 952-11 du code de l'éducation : « (...) Les professeurs émérites sont assimilés aux fonctionnaires et agents publics pour l'application des dispositions du code de la propriété intellectuelle ; ils sont notamment soumis aux dispositions des articles L. 113-9 et L. 611-7 du même code pour les logiciels et inventions à la création ou à la découverte desquels ils ont contribué dans le cadre de leur éméritat (...) ».

Ne sont a priori pas concernées :

- Les personnes qui ne sont pas " accueillies " et " placées sous l'autorité d'un responsable de la structure d'accueil " :
 - mandataire social non salarié, prestataire de service, consultant, entrepreneur ou porteur de projet incubé,
- Les personnes qui relèvent du droit commun des salariés et agents publics :
 - mandataire social salarié, intérimaire, salarié porté, salarié ou agent public détaché ou mis à disposition, doctorant salarié par la structure universitaire délivrant son diplôme de thèse.

En cas de cumul de positionnement, il est nécessaire, au préalable, de vérifier que l'activité du Créateur Indépendant pour la structure d'accueil est bien conforme aux règles applicables à son statut ou ses engagements existants. En effet, l'Ordonnance n'a pas vocation à s'appliquer à une personne déjà soumise au droit commun des Actifs de salariés ou assimilé. Ce sera par exemple le cas pour :

- Les chercheurs invités,
- Les doctorants salariés d'une structure autre que l'établissement délivrant leur diplôme de thèse.

Pour ces situations, il conviendra d'envisager au **cas-par-cas** les différentes chaines de droits applicables au Créateur Indépendant et ses différentes activités.

2.2 Les structures d'accueil

L'Ordonnance vise comme bénéficiaire de la dévolution des droits de propriété intellectuelle, la « personne morale de droit privé ou de droit public réalisant de la recherche ».

La formule tenant au lieu de l'accueil est extrêmement large puisqu'elle ne fixe aucune limitation. Elle ne prévoit notamment :

- Ni condition de forme ou de structure de l'entité. Sont donc concernées toutes les entités publiques ou privées :
 - société quelle que soit la forme (SA, SAS, SARL...) ou sa taille (startup, TPE/PME, grand groupe), dont le capital est privé ou public, dont les actions sont cotées ou non ;
 - établissement public quels que soient ses forme ou statut (EPA, EPIC, EPSCP, Grand Etablissement, AAI, collectivités territoriales...) ;
 - structure privée hors société (association, GIE avec personnalité morale...).
- Ni condition de forme ou de volume de la recherche. Sont donc concernées toutes les recherches :
 - recherche fondamentale ou appliquée ;
 - projet de recherche temporaire ou permanent ;
 - disposant d'une équipe/département dédié à la recherche ou non.

En revanche, il est nécessaire que la structure puisse accueillir le Créateur Indépendant. Ainsi, ne sont concernées que les entités bénéficiant de la personnalité juridique. Lorsque l'accueil est réalisé en pratique dans un espace sans personnalité morale (par ex. UMR, GIS), il conviendra d'identifier quelle est la tutelle ou la structure avec laquelle la convention est passée.

En pratique, le simple fait que la structure d'accueil réalise effectivement de la recherche semble suffire à caractériser la condition.

Par opposition, une structure qui ne réalise pas de recherche et accueille un Créateur Indépendant ne pourrait pas prétendre au bénéfice de l'application de l'Ordonnance. En d'autres

termes, un stagiaire ne cède pas automatiquement l'ensemble de ses droits sur ses Actifs à sa structure d'accueil, encore faut-il prouver que les autres conditions sont bien vérifiées.

3 Les critères d'application

3.1 Un accueil formalisé par une convention

Les Créateurs Indépendants ne sont soumis à l'Ordonnance que s'ils sont « **accueillis dans le cadre d'une convention** ».

L'Ordonnance ne retient aucune forme spécifique concernant la convention qui peut donc être formalisée par tout type de contrat dont l'objet et le contenu peuvent contenir non seulement l'accueil mais également d'autres éléments. Cette absence de forme permet également de considérer que la convention peut être signée par plus de deux personnes (par ex. dans le cas d'un accueil au sein d'une UMR ou pour la réalisation d'un consortium).

Concernant l'écrit, l'Ordonnance n'en fait pas expressément une condition de validité de la convention d'accueil.

Pour autant, **la Commission encourage à systématiquement privilégier une convention écrite** puisque tout autre aménagement des leurs droits respectifs par le Créateur Indépendant et l'entité d'accueil doit, quant à lui, être constaté par écrit.

En effet :

L.113-9-1 Auteurs de logiciels	L.611-7-1 Inventeurs
Pour ce qui concerne les logiciels, c'est le droit commun qui l'impose par l'article L.131-3 du code de la propriété intellectuelle qui liste les mentions obligatoires que doit comporter « <i>l'acte de cession</i> », obligatoirement écrit.	Pour ce qui concerne les inventions : l'Ordonnance précise que « <i>tout accord entre [le Créateur Indépendant et l'entité d'accueil] ayant pour objet l'invention réalisée par la personne physique doit, à peine de nullité, être constaté par écrit</i> ».

La convention visée par l'Ordonnance peut donc être matérialisée par tout type de document : convention de stage, d'accueil, de partenariat...

Bien entendu, toute convention qui organise un lien d'employeur/employé entre l'entité d'accueil et le Créateur Indépendant est exclue (puisque cela reviendrait à appliquer le droit commun des auteurs et inventeurs salariés).

La convention doit cependant formaliser un « accueil » et pas seulement une collaboration entre le Créateur Indépendant et l'entité d'accueil. Ce point est essentiel puisque **la simple présence d'un Créateur Indépendant au sein d'une structure n'implique pas nécessairement un accueil** : un consultant, un prestataire, un sous-traitant, un bénévole ne sont pas toujours accueillis. Or, en l'absence d'accueil, le régime de dévolution de l'Ordonnance ne s'applique pas.

La Commission considère que l'accueil ne doit pas être entendu dans un sens littéral de « présence physique » mais plutôt dans un sens conforme à l'esprit du texte de « présence dans l'organisation de l'entité d'accueil ». Ainsi, un Créateur Indépendant qui réaliserait tout ou partie de ses activités « en distantiel » (par ex. télétravail) tout en étant intégré dans l'environnement de l'entité d'accueil serait valablement considéré comme étant accueilli au sens de l'Ordonnance.

L'accueil doit en effet être envisagé en lien avec l'encadrement dont bénéficie le Créateur Indépendant.

3.2 Une situation d'autorité vis-à-vis d'un responsable de la structure d'accueil

L.113-9-1 Auteurs de logiciels	L.611-7-1 Inventeurs
L'Ordonnance dispose explicitement que le Créateur Indépendant ne sera concerné que s'il est « <i>placés sous l'autorité d'un responsable de ladite structure</i> ».	En matière d'invention, l'Ordonnance ne mentionne pas expressément la nécessité d'un placement sous une autorité particulière. Cependant, le régime des inventions de Créateurs Indépendant est formalisé par analogie avec le régime de droit commun des inventeurs salariés, qui sont quant à eux, systématiquement en position de soumission hiérarchique. En conséquence, la Commission a pour avis qu'il faudrait également, par analogie, rechercher ce positionnement hiérarchique ou, à tout le moins, une situation dans laquelle le Créateur Indépendant est encadré par une personne au sein de la structure. Si le Créateur Indépendant réalise une activité totalement autonome, sans aucun lien hiérarchique avec la structure, il est peu probable que ses Actifs soient couverts par l'Ordonnance. Ainsi, par exemple, la Commission considère que le président non salarié d'une SAS n'est pas placé en situation d'autorité vis-à-vis d'un responsable, et n'est donc pas concerné par le régime de dévolution de l'Ordonnance.

3.3 Une contrepartie

L.113-9-1 Auteurs de logiciels	L.611-7-1 Inventeurs
L'Ordonnance impose une contrepartie perçue par le Créateur Indépendant et renvoie au décret quant à son calcul. Le Rapport au Président de la République, quant à lui vise, en son Article 2, une « <i>contrepartie, financière et/ou matérielle</i> ».	L'Ordonnance prévoit, là encore par analogie avec les inventeurs salariés et agents publics, un mode de rémunération pour les

Il en ressort que la contrepartie peut prendre plusieurs formes et que l'Ordonnance n'entend pas imposer une contrepartie sous forme de rémunération. En conséquence, cette contrepartie pourrait ne pas consister dans le versement d'une somme d'argent. Cependant, l'analyse de la Commission tend à considérer que la mise à disposition des ressources strictement nécessaires à la réalisation de la mission du Créateur Indépendant pour la structure d'accueil, n'est pas suffisante pour constituer cette contrepartie. En effet, cette mise à disposition n'est pas une contrepartie, mais bien un préalable nécessaire pour que le Créateur Indépendant puisse réaliser la mission pour laquelle il est accueilli. La Commission considère que la gratification de stage constitue une contrepartie autorisant l'application de l'Ordonnance. La Commission attire l'attention du lecteur sur le fait que la contrepartie dont il est question ici est payée en complément de la prime due pour la cession (cf. tableau suivant sur les apports des décrets).	« inventions de mission » ou « inventions hors mission attribuables »⁴. Pour les inventions de mission que l'entité d'accueil souhaite revendiquer, le Créateur Indépendant perçoit une « <i>contrepartie financière</i> » dont les modalités ont été définies par décret (cf. 3.3 ci-dessous). Pour les inventions hors-mission attribuables dont l'entité d'accueil souhaite se faire céder la propriété, « <i>l'inventeur doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l'article L615-21 ou par le tribunal judiciaire</i> ».
---	--

Apport des décrets du 11 août 2023	
<u>Auteurs de logiciels</u>	<u>Inventeurs</u>
Les dispositions du décret propres aux auteurs de logiciels ont été codifiées aux articles D.532-2 à -6 du code de la recherche. Cette codification dans le code de la recherche et non pas dans le code de la propriété intellectuelle s'explique par le fait que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux Créateurs Indépendants travaillant pour des structures d'accueil « dont les	Dans ce même souci de tendre à unifier les régimes, le décret propose assez naturellement de distinguer entre les structures d'accueil selon le statut majoritaire de leur personnel de recherche permanent : salariés de droit privé ou agents publics. 1) Si plus de la moitié des personnels permanents de recherche sont des salariés de droit privé, le décret

⁴ Voir paragraphe 4.2 sur les différentes inventions couvertes.

<i>personnels permanents de recherche sont des agents publics</i> »⁵. Cette formule exclut les personnes morales dont les personnels permanents de recherche sont des salariés de droit privé, ce qui exclut donc en principe toutes les personnes morales de droit privé. La contrepartie financière est définie quasiment à l'identique de la rémunération due en application du décret dit « travaux valorisables »⁶ dont les dispositions sont aujourd'hui codifiées dans les articles D.532-2 à -6 du code de la recherche, à savoir : • 50% des revenus d'exploitation partagés entre les co-auteurs en fonction de leur contribution respective, • dans la limite du montant du traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au deuxième chevron du groupe hors échelle. • Au-delà de cette limite, le pourcentage est réduit à 25%. Là encore, cette tendance à rapprocher les régimes est bien conforme à l'esprit des textes.	renvoie au régime des inventions de salariés (R.611-1 à R.611-10 CPI). ➤ Bien entendu, là où le régime de droit commun des inventions de salarié fait appel « aux conventions collectives, accord d'entreprises et contrats individuels de travail »⁷, le décret ne peut lui que renvoyer au seul lien contractuel existant entre l'inventeur et la structure à savoir : la convention d'accueil. ➤ Pour aider les structures employant majoritairement des personnels sous statut privé à calculer cette contrepartie, le décret précise que « le montant de la contrepartie financière dont bénéficie cet inventeur tient compte des missions qui lui sont confiées, des circonstances de réalisation de l'invention, des difficultés pratiques de mise au point, de sa contribution personnelle à l'invention et de l'intérêt économique et commercial que la structure d'accueil pourra en retirer ». N.B. : c'est cette disposition qui tend à établir que cette contrepartie dont il est question vise bien à être à la fois une contrepartie pour le travail aboutissant à l'invention et une prime d'intéressement pour l'exploitation de l'invention. Ceci en contraste net avec ce qui est prévu pour les logiciels (cf. 3.4 ci-dessous). 2) Si plus de la moitié des personnels permanents de recherche sont des agents publics, le décret renvoie aux inventions de fonctionnaires et agents publics (R611-11 à R611-14-1 CPI).
---	--

⁵ En apparence, le recours au statut des personnels permanent semble étrange et l'on aurait pu préférer le recours au statut de la structure d'accueil. Au contraire, le choix du législateur est tout à fait cohérent. En effet, le régime de droit commun discrimine entre les personnes en fonction de leur statut (salarié ou agent public). Dans le cas des Créateurs Indépendants dont le statut varie d'une personne à l'autre, le législateur a choisi de recourir au statut majoritaire des autres personnels. Ceci afin d'assurer une cohérence au niveau de la structure, dans un souci d'égalité.

⁶ Décret n°96-858 du 2 octobre 1996 relatif à l'intéressement de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics ayant participé directement à la création d'un logiciel, à la création ou à la découverte d'une obtention végétale ou à des travaux valorisés : <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000005621856/>

⁷ Notamment L.611-7 CPI.

	➤ La contrepartie financière sera donc composée (i) d'une prime au dépôt de brevet (actuellement de 3 000 €, avec un premier versement de 20% au dépôt, le reste étant versé lors de la signature d'une concession de licence d'exploitation ou d'un contrat de cession dudit brevet) et (ii) une prime d'intéressement annuelle correspondant charges comprises, à 50 % de la base définie ci-dessus, dans la limite du montant du traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au deuxième chevron du groupe hors échelle D, et, au-delà de ce montant, à 25 % de cette base. N.B. : cette disposition tend donc à établir également que cette contrepartie ne vise pas une contrepartie pour le travail aboutissant à l'invention mais seulement une prime au dépôt et à l'intéressement pour l'exploitation de l'invention.
--	--

3.4 Contrepartie vs. Prime d'intéressement

La Commission attire l'attention du lecteur sur **une nuance importante qui est instituée entre les « auteurs » et les « inventeurs »**.

En matière de logiciel, la formulation initiale de l'Ordonnance laissait subsister une interprétation puisqu'il était tout à fait envisageable de considérer que la contrepartie n'est pas due en rémunération de la cession, mais de l'activité du Créateur Indépendant.

- « (...) [ils] se trouvent à l'égard de cette structure dans une situation où [ils] perçoivent une contrepartie et où [ils] sont placées sous l'autorité d'un responsable de ladite structure ».

- C'est bien cette interprétation qui est confirmée par les décrets, puisque l'article D.532-8 du code de la recherche dispose explicitement que « la prime d'intéressement est versée à l'intéressé, en complément de la contrepartie mentionnée à l'article L. 113-9-1 du code de la propriété intellectuelle (...) ».

En matière d'invention, la situation est moins claire puisqu'en l'absence d'une disposition équivalente à D.532-8, il semble donc que la contrepartie financière envisagée vient en rémunération exclusive de la dévolution des droits sur l'invention, pas en rémunération de la mission du Créateur Indépendant comme c'est le cas en matière de logiciel. Il s'agit bien d'un prix de cession/attribution.

N.B. : La Commission relève que cette nuance posée par les textes devra être éprouvée devant les juridictions pour en confirmer l'application.

3.5 Des exceptions ?

L.113-9-1 Auteurs de logiciels	L.611-7-1 Inventeurs
« Le régime des auteurs de logiciels s'applique "sauf stipulations contraires".	Le régime des inventeurs s'applique "à défaut de stipulation plus favorable à [l'inventeur]"

Dans les deux cas, l'exception renvoie aux mêmes réserves et interprétations que celles applicables aux régimes de droit commun des inventions et logiciels de salariés.

La Commission considère que l'interprétation et les réserves formulées sur ces exceptions dans le contexte du droit commun s'appliqueront *mutatis mutandis* dans le contexte du régime de l'Ordonnance.

4 Les Actifs visés

4.1 Les logiciels, leur documentation et les inventions...

L.113-9-1 Auteurs de logiciels	L.611-7-1 Inventeurs
L'Ordonnance vise « les logiciels et leur documentation ». Les logiciels sont couramment définis comme « l'ensemble des programmes, procédés et règles, et éventuellement de la documentation, relatifs au fonctionnement d'un ensemble de traitement de données »⁸. Bien que la notion de documentation soit souvent intégrée à la définition même de logiciel, l'Ordonnance suit la pratique déjà appliquée par l'art. 113-9 CPI et mentionne explicitement cette documentation dans les actifs faisant l'objet de la dévolution.	L'Ordonnance couvre l'ensemble des inventions susceptibles d'être protégées par un brevet. A noter, l'Ordonnance opère la même distinction que le régime de droit commun en précisant que : - Dans le cas des inventions de mission, c'est l'invention elle-même qui appartient à la structure d'accueil ; alors que ; - Dans le cas de l'invention hors-mission attribuable, c'est le droit de se faire « attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention » qui est dévolu à la structure.

⁸ Arrêté du 22 décembre 1981, relatif à l'enrichissement du vocabulaire informatique.

Tout autre actif ou droit de propriété intellectuelle est donc exclu du champ d'application de l'Ordonnance. Cette exclusion concerne notamment : les autres œuvres originales protégées par le droit d'auteur ou le droit voisin du droit d'auteur, les savoir-faire, les marques, les données, ou encore les bases de données, y compris lorsque certains de ces éléments pourraient entrer dans la notion de travaux valorisés donnant droit à un intéressement de certains fonctionnaires⁹.

Pour ces éléments, il convient donc d'organiser une cession expresse au cas par cas.

4.2 ... créés à l'occasion d'une mission ou activité confiée par la structure d'accueil

L.113-9-1 Auteurs de logiciels	L.611-7-1 Inventeurs
Ne sont concernées que les personnes réalisant un logiciel « <i>dans l'exercice de leurs missions ou d'après les instructions de la structure d'accueil</i> ».	L'Ordonnance vise les deux types d'inventions qui sont, comme dans le régime de droit commun, attribuées ou attribuables à la structure d'accueil. Ainsi, l'Ordonnance implémente une distinction bien connue du régime générale des inventions de salariés entre : Les « inventions de mission », c'est-à-dire « <i>les inventions réalisées par cet inventeur dans l'exécution soit d'une convention comportant une mission inventive qui correspond à ses missions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées</i> ». Les inventions « hors-mission attribuables », c'est-à-dire « <i>les inventions réalisées par cet inventeur dans l'exécution soit d'une convention comportant une mission inventive qui correspond à ses missions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées</i> ». A noter ces définitions reprennent <i>mutatis mutandis</i> celle de droit commun de l'art. L.611-7, 1° et 2°.

D'une façon générale, lorsque cela est possible, la Commission recommande de mentionner dans la convention d'accueil (ou tout autre écrit pertinent) que la mission, l'étude ou le projet qui conduit le Créateur Indépendant à être accueilli par la structure d'accueil comporte une activité de recherche et d'innovation pouvant certainement l'amener à réaliser des logiciels ou des inventions. De cette façon, l'activité du Créateur Indépendant sera présumée, sauf preuve contraire, remplir les conditions ci-dessus.

⁹ Décret n°96-858 du 2 octobre 1996 relatif à l'intéressement de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics ayant participé directement à la création d'un logiciel, à la création ou à la découverte d'une obtention végétale ou à des travaux valorisés.

<u>Apport des décrets du 11 août 2023</u>	
<u>Auteurs de logiciels</u>	<u>Inventeurs</u>
Le décret « logiciel » prévoit que la prime d'intéressement due s'appliquera selon deux conditions cumulatives¹⁰ : - aux créations logicielles réalisées après la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 15 décembre 2021 ; ET - dont l'exploitation par la personne morale de droit public a commencé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret. Le texte prévoit donc une application classique pour l'avenir. Les situations antérieures restant couvertes par le droit antérieur. En particulier, dans le cas d'un logiciel réalisé après l'entrée en vigueur de l'Ordonnance et donc l'exploitation aurait débuté avant l'entrée en vigueur du décret, les accords passés entre le Créateur Indépendant intéressé et la structure d'accueil s'appliquent.	Le décret « inventeur » précise son application de façon assez classique. D'une part, de façon assez attendue, toute invention déclarée postérieurement à l'entrée en vigueur de l'Ordonnance selon les modalités de déclaration de droit commun (R.611-1 à -141 CPI) et qui répond aux conditions d'application de l'Ordonnance (Créateur Indépendant, structure d'accueil de recherche...), est soumise aux dispositions du nouveau régime¹¹. C'est le fonctionnement normal de l'application de la loi nouvelle loi aux situations nouvelles. D'autre part, toute invention réalisée postérieurement à l'entrée en vigueur de l'Ordonnance mais qui n'a pas encore été déclarée à la date du décret : - doit obligatoirement faire l'objet d'une déclaration dans les conditions du droit commun (R.611-1 à -141 CPI)¹² et ; - se voit appliquer les dispositions du décret en fonction du statut des personnels de recherche permanent de la structure d'accueil¹³. C'est dire R.611-21 (salariés) et R.611-22 (agents publics). Dans un souci de sécurité juridique, le texte vient donc explicitement rapatrier l'invention réalisée entre l'Ordonnance et son décret d'application dans le champ de la réforme. Ceci afin d'éviter des questionnements quant à l'éventuelle application de dispositions transitoires.

¹⁰ Décret 2023-772, art. 4.

¹¹ Décret 2023-770, art. 4, I.

¹² Décret 2023-770, art. 4, II.

¹³ Décret 2023-770, art. 4, III.

5 Litiges

L.113-9-1 Auteurs de logiciels	L.611-7-1 Inventeurs
« Toute contestation sur l'application du présent article est soumise au tribunal judiciaire du siège social de la structure d'accueil ». Le décret « logiciel » ne prévoit aucune disposition complémentaire relative aux litiges ou contentieux. Le renvoi de l'article L.113-9-1 au tribunal judiciaire est par ailleurs conforme au principe de compétence exclusive des TJ en matière de propriété littéraire et artistique¹⁴.	Tout litige concernant la rémunération des Créateurs Indépendant inventeurs à la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou au tribunal judiciaire. <u>Modification de l'article R.615-33 et R.615-34 du CPI relatif à la Commission paritaire de conciliation</u> L'article 2 du décret « invention » étend la compétence de la commission paritaire de conciliation pour les litiges relatifs au droit de propriété intellectuelle des inventions des Créateurs Indépendants qu'il soit sous statut de droit privé ou agent public. Ainsi, elle est compétente d'une part pour trancher sur les questions relatives au contexte dans lequel une invention a été développée par le Créateur Indépendant, que ce soit dans le cadre de cadre d'une invention de mission ou hors mission (attribuable ou non) et, d'autre part, pour statuer sur la contrepartie financière.

N.B. : le Tribunal des Conflits a établi que le contentieux relatif à la rémunération supplémentaire des inventions des fonctionnaires ou agents publics de l'Etat et de ses établissements publics relève bien de la compétence de la juridiction judiciaire¹⁵.

¹⁴ Art. L.131-1 CP : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039280911

¹⁵ Tribunal des conflits, 11 avril 2016 : « (...) le contentieux relatif à la rémunération supplémentaire des inventions des fonctionnaires ou agents publics de l'Etat et de ses établissements publics relève de la compétence de la juridiction judiciaire, (...) et sauf à renvoyer à la juridiction administrative, par voie de question préjudicielle, l'appréciation de la légalité d'un acte administratif dont dépendrait la solution du litige, lorsque la question soulève une difficulté sérieuse et qu'il n'apparaît pas manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal ».

6 Conclusion

Aujourd'hui, la réforme du régime de dévolution des droits de propriété intellectuelle des inventions et des logiciels réalisés par des personnes non-salariées ni agents publics qui sont accueillies au sein de personnes morales réalisant de la recherche est aboutie.

Elle fournit un cadre que toute structure d'accueil peut mettre en place de façon à sécuriser le rapatriement des droits de propriété intellectuelle de ces Créateurs Indépendants qui travaillent en collaboration avec ses propres personnels de recherche.

Cette réforme s'efforce de maintenir les distinctions habituelles en la matière telles que « *invention vs. logiciel* » ou encore « *public vs. privé* » de telle façon que les praticiens peuvent dans une très grande part appliquer leurs mécanismes habituelles à ses nouvelles situations.

A la lumière de cette réforme (Ordonnance, décrets, codification), pour chaque projet d'accueil d'un Créateur Indépendant, la Commission recommande de vérifier :

- Que son **statut et ses engagements préalables** ne font pas obstacle à l'application de l'Ordonnance ;
- Que **les conditions de l'ordonnance** seront réunies :
 - Une convention d'accueil,
 - Un placement sous l'autorité d'un responsable,
 - Une mission ou une activité confiée par la structure d'accueil,
 - Une contrepartie ;
- Que la convention d'accueil **formalise** clairement ces conditions.

7 Ressources et liens utiles

- **Ordonnance** n° 2021-1658 du 15 décembre 2021 relative à la dévolution des droits de propriété intellectuelle sur les actifs obtenus par des auteurs de logiciels ou inventeurs non-salariés ni agents publics accueillis par une personne morale réalisant de la recherche : <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000044501327/>
 - **Communiqué de presse** sur l'Ordonnance : <https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2021-12-15#devolution-des-droits-de-propriete-des-non-salaries-ou-agent>
 - **Rapport au Président de la République** relatif à l'Ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021 relative à la dévolution des droits de propriété intellectuelle sur les actifs obtenus par des auteurs de logiciels ou inventeurs non-salariés ni agents publics accueillis par une personne morale réalisant de la recherche, NOR : ESRR2134326P : <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044501320>
- **Décret** n° 2023-770 du 11 août 2023 relatif aux modalités de dévolution des droits de propriété industrielle sur les actifs obtenus par des inventeurs non-salariés ni agents publics accueillis par une personne morale réalisant de la recherche : <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000047964851/>
- **Décret** n° 2023-772 du 11 août 2023 relatif à l'intéressement des auteurs de logiciels non-salariés ni agents publics accueillis par une personne morale de droit public réalisant de la recherche dont les personnels permanents de recherche sont des agents publics : <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000047964885/>
- **Décret** n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche : <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000048716107/>
- **Décret** n°96-858 du 2 octobre 1996 relatif à l'intéressement de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics ayant participé directement à la création d'un logiciel, à la création ou à la découverte d'une obtention végétale ou à des travaux valorisés: <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000005621856/>

* * *